

1501767-16.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas."

(TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a):

Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501767-16.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312223/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN DOS REIS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 28 dias do mês de abril de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressuto e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) IVAN DOS REIS e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo e Hélio Pereira Nogueira.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Wanderson e Hélio) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

IVAN DOS REIS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 18h20, na Alameda João Batista Camargo Mendes, altura do número 72, Bairro Cecap, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 15 (quinze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), e 30 (trinta) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., "maconha", com peso líquido de 66,8g (sessenta e seis gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente notificado a fls. 90, o réu apresentou defesa prévia a fls. 94/97. A denúncia foi recebida a fls. 108/110. Na instrução o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas.

É a síntese necessária.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, fotografias de fls. 13, laudo de constatação de fls. 15/17 e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 106/107.

A autoria do crime descrito na denúncia restou comprovada.

O policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo relatou, na fase policial, que "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com um homem que, ao notar a presença das motocicletas policiais, tentou se evadir, dispensando uma sacola plástica que trazia consigo. Que, após breve acompanhamento, lograram deter o suspeito, posteriormente identificado como IVAN DOS REIS, quando já se encontrava na alameda João Baptista Camargo Mendes, nesta urbe. Que, com IVAN, foram localizados R\$ 16,00 em notas miúdas e também um celular. Que, após vistoria, foi verificado que, dentro da sacola dispensada por ele, havia 30 porções de substância análoga à MACONHA e 15 invólucros plásticos contendo aparentemente COCAÍNA. Que, indagado, o implicado confessou informalmente que estava realizando o tráfico de drogas. Que, tendo em vista os fatos acima, tudo denotando a prática do tráfico de drogas, os agentes da Lei encaminharam o suspeito a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas" (fls. 03).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva. Disse que, ao avistar a viatura, o acusado jogou uma sacola na direção de um telhado e empreendeu fuga, sendo posteriormente detido. Em seguida, constataram que, na sacola que havia sido dispensada, havia as substâncias entorpecentes indicadas na denúncia. Também foram apreendidos R\$ 16,00 e um telefone celular. Na ocasião, o réu confessou a prática do tráfico de entorpecentes. Informou que o acusado estava à pé e correu "por um bom pedaço", sendo que a própria população tentou ajudar os policiais.

Esclareceu, ainda, que o acusado mencionou que também correu em razão de um mandado de prisão expedido em outro processo.

Por sua vez, o policial militar Hélio Pereira Nogueira contou, na fase policial, que "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com um homem que, ao vê-los, esboçou atitude suspeita, típica do tráfico de drogas. Que tal homem tentou se evadir, dispensando uma sacola plástica que trazia consigo. Que, após breve acompanhamento, lograram deter o suspeito, posteriormente identificado como IVAN DOS REIS, quando já se encontrava na alameda João Baptista Camargo Mendes, nesta urbe. Que, com IVAN, foram localizados R\$ 16,00 em notas miúdas e também um celular. Que, após vistoria, foi verificado que, dentro da sacola dispensada por ele, havia 30 porções de substância análoga à MACONHA e 15 invólucros plásticos contendo aparentemente COCAÍNA. Que, indagado, o implicado

confessou informalmente que estava realizando o tráfico de drogas. Que, tendo em vista os fatos acima, tudo denotando a prática do tráfico de drogas, os agentes da Lei encaminharam o suspeito a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas" (fls. 04).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia. Esclareceu que foi o responsável pela apreensão da sacola em que estavam as drogas, no telhado de uma garagem baixa, enquanto seu parceiro realizou a abordagem. Com o acusado foram apreendidos dinheiro e celular. Teve certeza de que a sacola apreendida foi a que havia sido dispensada pelo acusado. O acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Confirmou que, dias depois, foi expedido um mandado de prisão em desfavor do réu, o que também deve ter motivado a fuga desenfreada do acusado. Indagado sobre a cocaína apreendida, disse que apenas se recordava da maconha, mas é possível que também houvesse cocaína, sendo que, ao depor na fase policial, indicou com exatidão as drogas apreendidas.

O réu, interrogado no inquérito policial, optou pelo silêncio (fls. 06).

Em juízo, admitiu que, ao visualizar os policiais, arremessou 15 pinos de cocaína que trazia consigo sobre um telhado. Alegou, contudo, que a droga se destinava ao próprio consumo. Negou ser proprietário da maconha apreendida.

A versão apresentada, contudo, não resiste aos demais elementos de prova colhidos. Dessa forma, encerrada a instrução, a imputação restou devidamente comprovada.

No que tange à palavra dos policiais, importante observar que foi corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, mormente pela apreensão da droga em poder do acusado, o que corrobora as informações recebidas pelos agentes.

Portanto, merecem credibilidade os depoimentos dos policiais diante da coerência e harmonia com o restante do acervo probatório, além do que, sequer possuíam motivos para incriminá-lo.

Com efeito, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/64), de maneira que é "inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372 e, no mesmo sentido, STRTJ 68/54).

Pequenas divergências com relação a aspectos secundários da prova são até mesmo esperados, em razão das inúmeras ocorrências atendidas diariamente, não retirando a credibilidade dos relatos prestados.

Desse modo, considerada a quantidade de entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento da substância, e a confirmação da prova em juízo, indubitável que a droga destinava-se à comercialização.

Assim, comprovadas materialidade e autoria delitivas a condenação é medida que se impõe.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias não são favoráveis ao acusado, considerado o histórico de maus antecedentes a fls. 37/48, razão pela qual a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena. O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas não se aplica, no presente caso, ante a reincidência e aos maus antecedentes.

Diante da reincidência, incabível substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (artigo 44 da Lei nº 11.343/06). Ademais, o réu deverá iniciar o desconto da pena no regime fechado.

Requeiro, ainda, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, com fulcro nos artigos 61 e 63, da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Ante o exposto, requer a procedência da ação nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Ivan dos Reis foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 82-83), no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 18h20, na rua Alameda João Batista Camargo Mendes, altura do número 72, bairro Cecap, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Ivan trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 15 (quinze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), e 30 (trinta) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., "maconha", com peso líquido de 66,8g (sessenta e seis gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, policiais militares, em patrulhamento, perceberam que o réu, ao ver a viatura, dispensou uma sacola plástica no chão e iniciou fuga. Após breve perseguição, detiveram-no e, em revista pessoal, encontraram R\$16,00 (dezesseis reais) e um telefone celular. Na sequência, recuperaram a sacola dispensada e encontraram em seu interior as drogas acima mencionadas. Aos militares, o réu confessou o tráfico de drogas no local. Na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (fls. 6).

Interrogado em solo policial, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 6).

Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo, policial militar, contou que: "estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com um homem que, ao notar a presença das motocicletas policiais, tentou se evadir, dispensando uma sacola plástica que trazia consigo. Após breve acompanhamento, lograram deter o suspeito, posteriormente identificado como Ivan dos Reis, quando já se encontrava na alameda João Baptista Camargo Mendes, nesta urbe. Com Ivan, foram localizados R\$ 16,00 em notas miúdas e também um celular. Após vistoria, foi verificado que, dentro da sacola dispensada por ele, havia 30 porções de substância análoga à maconha e 15 invólucros plásticos contendo aparentemente cocaína. Indagado, o implicado confessou informalmente que estava realizando o tráfico de drogas. Tendo em vista os fatos acima, tudo denotando a prática do tráfico de drogas, os agentes da Lei encaminharam o suspeito a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Hélio Pereira Nogueira (fls. 4).

Às fls. 37-41, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0000529-12.2016.8.26.0599 - furto - trânsito em julgado para a Defesa em 20/3/2017; autos n.º 0002400-70.2015.8.26.0451 - tráfico - trânsito em julgado para a Defesa em 30/6/2015, pena cumprida ou julgada extinta em 6/12/2016; autos n.º 0005885-80.2019.8.26.0502 - furto qualificado - trânsito em julgado para a Defesa em 27/3/2019).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, fotografia de fls. 13, laudo de constatação preliminar de fls. 15-17 e laudo de exame definitivo de fls. 105-107.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvido, inicialmente, o policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo. Estavam em patrulhamento no bairro CECAP. É policial da ROCAM, patrulhava o local de moto com o parceiro. Visualizaram Ivan e, quando ele viu a viatura, jogou uma sacola em cima de um telhado. O depoente acompanhou o réu, ele tentava correr, e o parceiro ficou para resgatar a sacola. O réu resistiu, foi necessário o uso de algemas. Em revista pessoal, localizaram R\$16,00 e um aparelho de telefone celular. O local era ponto conhecido pela venda de drogas. Ivan estava a pé, a população tentou ajudar a pegá-lo. A sacola foi localizada no telhado. Havia 30 porções de maconha e 15 pinos de cocaína. Quando foi visualizado, Ivan estava sozinho quando avistado? Sim. Depois, a rua lotou de populares, houve quem tentou ajudar a detê-lo. O réu, informalmente, confessou a traficância. Disse que fugiu porque teve receio de "estar pedido". No dia seguinte, foi expedido o mandado de prisão no outro processo.

Na sequência, foi ouvido Hélio Pereira Nogueira, policial militar. Também é policial da ROCAM. Estava em patrulhamento com o parceiro. Entraram em uma rua, ele e o parceiro avistaram Ivan, que jogou uma sacola em um telhado e saiu correndo. O depoente parou para resgatar a sacola. Nela havia porções de maconha. Não se recorda se havia mais entorpecentes, mas acredita que era só maconha. O parceiro perseguiu o réu. Com o réu, preso pelo parceiro, tinha 16 reais e um telefone celular. Ao avistarem Ivan, ele estava a pé e sozinho. Informalmente, Ivan confessou que estava no local vendendo. Perguntado pelo MP sobre a cocaína informada como parte da apreensão no boletim de ocorrência, disse que não se recorda, pois são muitas ocorrências e não pode analisar o BO antes da audiência. [Por qual motivo o réu disse que correu?] O réu, de início, negou a traficância. Depois, ao ser mostrada a ele a sacola com drogas, ele assumiu o tráfico. Além disso, foi expedido mandado de prisão 1 ou 2 dias após os fatos em razão de outro delito, e acredita que ele também deve ter fugido por achar que “estava pedido”. Por fim, foi interrogado o réu Ivan dos Reis. Estava com uma menina, que viu a ROCAM se aproximando. Jogou os 15 pinos de cocaína que tinha consigo. Abordado, disse que não tinha jogado nada. Ficou com medo e fugiu. Duas quadras depois, foi abordado novamente e acabou confessando que tinha jogado no telhado os 15 pinos de cocaína. Saiu do trabalho, tinha 160 reais, comprou 15 pinos de cocaína. Sobraram 16 reais. Ia comprar cigarro e isqueiro com esse dinheiro e depois ia para casa usar a droga. A maconha apreendida foi apresentada na hora pelos policiais. Eles disseram que, se ele não indicasse os donos da biqueira, iam prendê-lo por tráfico e colocar a maconha junto na ocorrência. Indicou aos policiais onde estavam as suas drogas. Faz uso de cocaína. Antes, era viciado em crack, mas conseguiu parar. Na época da prisão, conseguia ficar alguns dias sem usar, mas quando recebia o pagamento, comprava drogas. Estava no local porque a menina com quem estava foi quem lhe vendeu a droga. Ela tinha ido buscar a droga e acabado de lhe entregar. [Por que correu?] Porque mentiu inicialmente para os policiais e eles estavam lhe ameaçando de implicar a maconha. A menina, quando a ROCAM chegou, continuou andando, mas ele foi abordado.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

De rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, caso se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do

delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga e a quantidade de entorpecente apreendida na posse do réu é compatível com o uso de drogas.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme relatou em seu depoimento, Ivan tinha consigo apenas 15 porções de cocaína, para uso próprio. A implicação de outras porções de drogas, como a maconha, é controversa, até porque os policiais foram contraditórios em seus depoimentos.

No mais, exigir da pessoa presa que indique quem era o traficante, em um Estado no qual não se protege testemunhas e sabidamente quem delata é castigado, é pedir que a pessoa se coloque em risco sem qualquer repaldo estatal.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS

(Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

Outrossim, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário

demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder dos acusados se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

“PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo” (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, e mostra-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e exsurtem algumas consequências.

a) Da absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição em razão da inconstitucionalidade do referido tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: “Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]” (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344). Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: “O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art.

386, III, do Código de Processo Penal.

b) Da aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas
Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência permite o aumento da pena em 1/6.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado. Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

IVAN DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 18h20, na Rua Alameda João Batista Camargo Mendes, altura do número 72, Bairro Cecap, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 15 (quinze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), e 30 (trinta) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., "maconha", com peso líquido de 66,8g (sessenta e seis gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento, perceberam que o réu, ao ver a viatura, dispensou uma sacola plástica no chão e iniciou fuga.

Após breve perseguição, detiveram-no e, em revista pessoal, encontraram R\$ 16,00 (dezesesseis reais) e um telefone celular.

Na sequência, recuperaram a sacola dispensada e encontraram em seu interior as drogas acima mencionadas.

Aos militares, o réu confessou o tráfico de drogas no local. Na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (fls. 06).

Considerando as circunstâncias da prisão, o local dos fatos conhecido como ponto de venda de drogas, a apreensão de dinheiro, quantidade, diversidade e forma de embalagem dos entorpecentes, é certo que o réu os trazia consigo com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 81), sendo determinada a notificação do réu para

oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 84/85). O réu foi notificado (fls. 90) e apresentou defesa prévia, na qual requereu a concessão de liberdade provisória e alegou inocência (fls. 94/97). A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 108/110). O réu foi citado (fls. 127).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fl. 12, na fotografia de fls. 13, no laudo de constatação de fls. 15/17, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 106/107, segundo o qual foi detectada a presença das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), nos materiais apreendidos.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 06).

Em Juízo, o réu afirmou que estava na avenida com uma menina que, hoje, está presa. Estavam andando na calçada. Ela olhou para trás e disse: a Rocam está vindo. Nesse momento, pegou os 15 pinos de cocaína que tinha e jogou em cima do telhado. Eles o abordaram e perguntaram o que tinha jogado. Negou que tivesse jogado alguma coisa. Nesse momento, saiu correndo. Depois, foi detido novamente e o policial perguntou o que tinha jogado. Contou que tinha jogado 15 pinos de cocaína. O policial disse que se contasse quem soltava droga no Cemap, seria liberado, mas não falou nada, porque tem medo de represálias. Tinha saído do serviço, após às 17h15. Estava com R\$ 176,00. Comprou 15 pinos de cocaína e sobrou R\$ 16,00. Iria comprar cigarros e voltar para casa, para consumir a droga. A maconha apreendida foi apresentada pelos policiais, dizendo eu se não desse o dono da "biqueira", iriam lhe prejudicar. Disse aos policiais que poderiam ir até onde jogou os pinos de cocaína, que era só isso que tinha. Explicou aos policiais onde estavam os pinos de cocaína. Os policiais viram o que tinha jogado, porque eles lhe perguntaram o que havia jogado. Faz uso de cocaína e conseguia focar sem consumi-la, até o dia do pagamento, mas com dinheiro, acabava comprando e usando. Estava no local, porque a menina tinha ido buscar os pinos de cocaína para ele. Quando estavam caminhando juntos, ela avisou que a Polícia estava chegando. Correu dos policiais, porque tinha mentido que não tinha jogado nada e eles já tinham mostrado uma outra quantia. Conhece essa menina e até mencionou o nome dela aos policiais, no momento da abordagem. Os policiais não acreditaram nele. Os policiais só o abordaram, permitiram que a menina continuasse caminhando. Se ela fosse abordada, teriam encontrado drogas com ela.

A autoria restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos.

O policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo asseverou que estavam em patrulhamento pelo bairro Cemap, em local conhecido como tráfico de drogas, próximo de escola, quando visualizaram o réu a pé e sozinho. Assim que viu a viatura, o réu jogou uma sacola por cima de um telhado de uma casa e saiu do local correndo.

Perseguiu o réu e seu parceiro ficou para pegar a sacola. Estava em motocicleta. A todo momento, o réu resistiu e precisou usar algemas. Seu parceiro conseguiu encontrar a sacola, onde havia 15 pinos de cocaína e 30 porções de maconha. Com o réu, em revista pessoal, havia R\$ 16,00 e um celular. O réu confessou a prática de tráfico de drogas e disse que tinha corrido, porque estava "pedido" e, de fato, confirmaram que no dia seguinte foi expedido mandado de prisão. Não conhecia o réu. O local é uma comunidade. A Polícia chega e começa a acompanhar alguém, a rua lota. No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Hélio Pereira Nogueira, segundo o qual estavam em patrulhamento e, quando entraram na via, avistaram o réu a pé e sozinho. Viu que ele jogou alguma coisa no telhado e, por isso, parou. O réu saiu correndo e seu parceiro seguiu atrás dele, até que conseguiu abordá-lo.

Conseguiu pegar em cima do telhado da garagem, a sacola que ele dispensou. Dentro da sacola havia porções de maconha. Em revista pessoal, com o réu, havia dinheiro e celular. Questionado, o réu confessou que estava no local fazendo a venda da droga. Não conhecia o réu. Recorda-se do que aconteceu, mas não sabe o que havia dentro da sacola corretamente. Um ou dois dias depois, tiveram conhecimento de que saiu um mandado de prisão. Ele correu, porque tinha droga consigo. O réu, a princípio, negou a prática delitiva, mas quando lhe mostraram a sacola com as drogas, acabou confessando.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, que se manifestou apenas em solo judicial, alegou que apenas estava na posse da cocaína, que era para seu próprio consumo. Desconhecia a maconha apreendida. Já os policiais militares narraram que avistaram o réu em local já conhecido como ponto de venda de drogas e ele, ao perceber a aproximação da viatura, esboçou atitude suspeita e tentou se evadir, dispensando uma sacola plástica que trazia consigo, jogando-a no telhado de uma garagem. O policial Wanderson conseguiu abordar o réu enquanto Helio encontrou a sacola dispensada pelo réu. Em revista pessoal, com ele, foram localizados R\$ 16,00 em notas trocadas e um celular. Na sacola dispensada, havia 30 porções de maconha e 15 invólucros plásticos de cocaína. Helio falou que só havia cocaína, mas não pode confirmar essa quantia. Indagado, informalmente, o réu confessou que estava realizando o tráfico de drogas. Nesse sentido, existem duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, que alega que havia apenas consigo 15 porções de cocaína, e a dos policiais militares, segundo os quais o réu estava na posse da sacola com a droga, mas a dispensou, antes da abordagem.

Nesses termos, é preciso verificar qual versão merece credibilidade.

Inicialmente, o réu não tem a obrigação de dizer a verdade, podendo, como fez na fase policial, permanecer calado. A isso se contrapõe o fato de os policiais militares estarem obrigados a falar a verdade.

De outro lado, o réu foi avistado em local conhecido como ponto de venda de drogas e, ao perceber que poderia ser abordado, tentou fuga.

Por fim, os policiais militares foram unânimes em afirmar que presenciaram o momento em que o réu dispensou a sacola onde a droga foi localizada.

Entendo, portanto, que a versão dos policiais se sobrepõe à palavra do réu e é suficiente para a certeza de que o réu estava na posse da droga apreendida, que dispensou, ao perceber a aproximação policial.

Ademais, a palavra dos policiais militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal. Ressalto que o depoimento das autoridades foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg.

Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do

édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Por fim, eventuais contradições quanto à quantidade e qualidade da droga não contaminam a segurança dos depoimentos dos policiais militares, já que não comprometem a essência da prova testemunhal. Ademais, os policiais efetuam grande quantidade de apreensões de drogas e exigir-se que recordem-se da quantidade e qualidade de toda a droga não seria cabível.

Sobre o assunto:

PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Denúncia que qualificou o acusado e descreveu pormenorizadamente a conduta imputada, com todas as elementares e circunstâncias atinentes à infração penal, além de ter apresentado rol de testemunhas, baseando-se em suporte probatório mínimo. NULIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DE CONSTATAÇÃO COM "FALHAS". NÃO OCORRÊNCIA. Não verificadas falhas nos documentos apontados, mesmo porque não houve qualquer indicação de quais falhas seriam. E, ainda que se verificasse a existência de tais "falhas", não teriam elas o condão de ensejar a nulidade do feito ab initio, porquanto eventuais vícios ou nulidades ocorridas no inquérito policial não têm o condão de macular o processo penal. Ademais, a douta Defesa sequer comprovou o prejuízo que, em tese, teria suportado em virtude de tais "falhas" apontadas. Nulidades não verificadas, portanto. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. Configuração do tráfico. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Acusado preso em flagrante delito trazendo consigo e guardando próximo de si 49 porções de cocaína (34,1g). Acusado silente em solo policial ; em juízo, admitiu a propriedade dos entorpecentes, mas negou seu envolvimento com o tráfico, apresentando-se como usuário, versão que não encontra respaldo no restante da prova produzida. Versões dos policiais miliares que se mostraram firmes, coesas e coerentes, mesmo porque pequenas divergências ou contradições nos depoimentos dos agentes policiais não comprometem a essência e integralidade da prova testemunhal, mormente quando eventual incongruência recai em pontos não essenciais, sem afetar a reconstrução do fato criminoso contido na acusação formal. Demais testemunhas presenciais que confirmaram o encontro das drogas. Informantes que não presenciaram os fatos e se restringiram a falar sobre as atividades à época exercidas pelo acusado e o fato de ser ele usuário de drogas. Condenação mantida. PENA E REGIME. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, pela natureza do entorpecente, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa mínimos, o que de acordo com os dizeres do artigo 42 da lei de regência. Manutenção. Inexistência de agravantes ou atenuantes. Considerados preenchidos os requisitos, foi concedido o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), o que se mantém, ante a resignação ministerial. Apenamento final fixado em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da quantia em dinheiro apreendida, em notas trocadas, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a gravidade concreta do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a absoluta incompatibilidade de tais benesses com o regime de pena cabível e a insuficiência delas à prevenção e à repressão do delito. Recurso defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500591-53.2018.8.26.0616; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019).

Ainda que assim não fosse, o importante é que o réu tinha consigo drogas. Ressalto que os policiais militares não conheciam o réu e se quisessem prejudicá-lo poderiam ter feito com menor quantidade de drogas.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que a cocaína estava em seu poder e seria para seu próprio consumo. A prova dos autos, no entanto, confirma a destinação e consumo de terceiras pessoas.

O local onde o réu foi avistado inicialmente era conhecido como ponto de venda de droga, de forma que o réu não estaria no local, sem essa motivação.

Ao avistar os policiais e perceber que poderia ser abordado, o réu iniciou fuga e dispensou a sacola que trazia consigo, demonstrando conhecimento sobre o conteúdo ilícito dela.

Dentro da sacola, havia entorpecente, cuja quantidade, diversidade e forma de embalo (30 porções de maconha e 15 porções de cocaína) revelam que se destinava ao consumo de terceiras pessoas, porquanto usuários não os mantêm fora de casa.

Com o réu, os policiais encontraram dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada.

Além disso, aos policiais, informalmente, o réu confessou que estava na prática do tráfico de drogas.

Ademais, a alegação do réu de que tinha adquirido a droga da garota com quem caminhava não merece respaldo, porquanto os policiais foram unânimes em afirmar que não havia nenhuma moça na sua companhia. Ademais, se o réu conhecia a garota, poderia tê-la arrolado como testemunha.

Assim, o local em que o réu foi visualizado, a tentativa de fuga e dispensa da droga, a quantidade e diversidade do entorpecente, a existência de dinheiro e a confissão informal; tudo confirma que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de

aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação